

1503070-94.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... de anotações com a contabilidade do tráfico, evidenciam que WESLLEY praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 245/246).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 279/297).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503070-94.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503070-94.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250724/2020 - 02º D.P. CUBATÃO, 14038795 - 02º D.P. CUBATÃO, 351/20/229 - 02º D.P. CUBATÃO, 2250724 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WESLLEY CASTILHO DE BRITO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

I - RELATÓRIO

WESLLEY CASTILHO DE BRITO SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei 10.826/03. Isto porque, segundo a denúncia, no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Beira Mar, nº 140, Vila Siri, Cubatão, WESLLEY CASTILHO DE BRITO SILVA, qualificado a fls. 08, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 108 porções de maconha, com peso bruto de 295g, e 310 porções de cocaína, com peso bruto de 310g,

causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 12/13 e auto de constatação preliminar de fls. 07. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, WESLLEY CASTILHO DE BRITO SILVA possuía e tinha em depósito 04 munições de arma de fogo, calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 06/08 e laudo pericial de fls. 72/75. Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares estavam em operação de combate ao tráfico de drogas, momento em que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença dos milicianos, passou a correr e adentrou em uma residência. Em razão da atitude suspeita, os policiais militares foram ao seu encalço e lograram êxito em abordá-lo já no interior da residência. Em buscas no interior do imóvel, os policiais militares encontraram uma sacola, no interior da qual estavam armazenados 183 eppendorfs de cocaína (310g – peso bruto) e 108 porções de maconha (295g – peso bruto), além de R\$ 170,00 em dinheiro trocado, um dichavador e duas folhas de papel com contabilidade do tráfico de drogas. Na sequência, logram êxito em encontrar, armazenado em uma saboneteira localizada no banheiro da casa, 04 munições de arma de fogo intactas de calibre 9mm. A abordagem policial foi acompanhada pela companheira do denunciado, Crislaine Ferreira dos Santos. A quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, o seu modo de acondicionamento, aliados às circunstâncias da apreensão, a qual envolveu, inclusive, o encontro de petrechos utilizados no comércio espúrio, a exemplo de anotações com a contabilidade do tráfico, evidenciam que WESLLEY praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 245/246). O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 279/297). Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a absolvição. A Defesa, por sua vez, requereu a nulidade das provas e absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da ilicitude das provas colhidas contra o réu. É o breve relatório. Fundamento e decido.

II – PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado. Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais. Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III – MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC – e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 “representa uma nova política na seara das drogas” (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: “todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados” (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral.

10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., RESp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 03/05), termo de depoimento (fls. 10/11, 14, 16), auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 66/75), relatório final (fls. 100/101), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, duvidosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido não foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciará.

Vejamos:

Em solo policial, a testemunha CRISLAINE FERREIRA DOS SANTOS disse que “é esposa do indiciado WESLLEY, vivendo em união estável conjugal há aproximadamente um ano. Neste Período, seu marido não foi preso em qualquer oportunidade, sendo que, apenas assina, comparecendo ao fórum, referente a outras passagens, inclusive por roubo. Está de resguardo, por ocasião do nascimento de gêmeos, recém nascidos. WESLLEY não trabalha atualmente, sendo socorridos pela mãe da depoente e seu avô, presente nesta distrital. Com relação ao evento presente, quando chegou às sua residência os policiais militares já estavam no interior do imóvel, sendo que a droga apreendida verdadeiramente estava na sua residência. Tinha conhecimento que seu marido estava envolvido com algo errado, mas não tinha conhecimento que havia este material entorpecente em sua casa. Não presenciou qualquer maltrato ou agressão contra seu marido. Sabia que desde a época de adolescente, WESLLEY tem má conduta. Coloca-se à disposição para quaisquer outras declarações” (fls. 11).

Em Juízo, disse que é companheira do Réu. Residiam naquela localidade por quase 01 ano. O Réu já havia sido preso, mas não se recorda pelo que, pois não estavam juntos naquele momento. No dia dos fatos estava de resguardo porque teve gêmeos. Na época o réu estava desempregado. Quem auxiliava era seu avô e mãe. No dia dos fatos não estava dentro da casa. Chegou quando os policiais estavam dentro da residência, juntamente com o Réu, que estava amarrado. Os policiais não apresentaram droga nenhuma dentro da residência. Em delegacia não disse que a droga era de seu Réu. Foi para a delegacia porque os policiais a levaram. Nunca falou que a droga estava dentro da sua residência. Não leu o depoimento prestado, mesmo com advogado. Não tinha conhecimento que o Réu, seu marido, estava envolvido com algo errado. O que mais teve foi agressões contra seu marido. Em delegacia não falou que não houve agressões. Não se recorda se assinou o documento ou não. Seu advogado, Dr Severino, esteve ao seu lado o tempo todo. Não permitiu a entrada da casa da polícia, pois quando chegou na localidade os policiais já estavam dentro. Foi agredida verbalmente pelos policiais, que falaram “coloca um DIU em sua buceta e para de fazer filho com vagabundo”. Não mostraram nenhuma droga. Um dos policiais saiu do banheiro com uma saboneteira, dando risada, “quando for revistar, revista direito, olha o que eu encontrei”.

Em solo policial, o condutor e testemunha WILSON ROBERTO NUNES JUNIOR disse que “é

policial militar, mais precisamente SARGENTO da ROTA - Rondas Tobias de Aguiar, e hoje estavam executando com os demais colegas policiais, uma operação na Vila dos Pescadores, procedendo à pé, quando percebeu à distância um indivíduo que, ao vê-los, pôs-se a correr, sendo acompanhado pelo depoente e outros policiais. O indivíduo adentrou em uma residência, sendo detido e, de imediato, foi dizendo que aquela seria a sua residência. Identificado como WESLLE CASTILHO DE BRITO SILVA, indagado por qual razão evadira-se, nada disse. Indagado se havia de ilícito na residência, a princípio negou. Todavia, neste momento, adentrou a Sra. Crislaine, identificada com a esposa de WESLLEY. Com a permissão de CRISLAINE passaram a procurar algo ilícito, quando WESLLEY indicou uma sacola colorida, afirmando que no seu interior havia drogas e valores. Da mesma forma, no banheiro, no interior de uma saboneteira havia quatro cartuchos de calibre 9 mm, intactos. Sobre uma mesa, localizaram-se duas folhas de papel, contendo anotações sobre o comércio ilícito de droga e um deschavador, instrumento usado para triturar o entorpecente conhecido como maconha. Quando se dispunham a vir à distrital, surgiu um indivíduo, identificado como irmão de CRISLAINE, WAGNER FERREIRA DOS SANTOS, que passou a proferir injúrias contra os policiais presentes. Encaminhados todos à unidade distrital, apresentados ao Delegado de Polícia signatário, elaborando-se exames periciais e decorrendo em positividade para a entorpecência do material apresentado, cocaína e maconha, deu-se a WESLLEY a voz de prisão pelas condutas apresentadas e a WAGER, elaborou-se o TERMO CIRCUNSTANCIADO por DESACATO" (fls. 14).

Em Juízo, disse que se recorda um pouco dos fatos. Estavam em operação pela Vila dos Pescadores e, ao desembarcarem, visualizaram o Réu adentrando em uma residência. Em busca pessoal nada foi encontrado. Quando efetuaram a busca pessoal chegou uma mulher de nome Cristiane. Ela confirmou que o Réu era seu companheiro. O Réu informou que havia uma sacola colorida em um cômodo da residência contendo drogas e dinheiro. Em continuação de buscas na residência foram encontradas 4 munições de calibre 9mm. Informalmente o Réu disse que havia passado a noite traficando. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores. Foi coincidência visualizar o Réu na localidade. Os batalhões efetuam operações naquele local com alguma frequência. A atitude suspeita do Réu foi porque veio de encontro, saindo de uma viela e, ao notar a abordagem policial, mudou a direção. Estavam a poucos metros e o Réu entrou correndo na residência. Os fundos da residência é água e a fuga, provavelmente, seria por aí. Conseguiram deter no cômodo dentro de casa. Não se recorda a quantidade nem a espécie de drogas dentro da sacola. Recorda-se que a quantidade era para a mercancia. Não se recorda de valores, mas havia dinheiro. Na mesma sala, inclusive, havia anotações do tráfico. A esposa do Réu chegou após 1 minuto na localidade, quando efetuaram a busca pessoal. Não houve tempo para informar que realizaram uma busca/varredura na residência. Três policiais entraram no imóvel. Não se recorda quanto tempo demorou a diligência policial, mas não foi muito. Não houve utilização de cão farejador. Quando o réu correu não visualizaram nada sendo arremessado ou jogado. Em busca pessoal também não encontraram nada. Quando localizaram a sacola foi exposta no sofá da sala, juntamente com as munições e anotações, encontradas posteriormente. Não precisaram algemar a esposa do Réu. O que chamou atenção no Réu foi ele ter colocado a mão na cintura e por isso correram atrás do mesmo. A busca pessoal foi dentro da residência.

Em solo policial, a testemunha ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA disse que "é policial militar, em exercício nas Rondas Tobias de Aguiar, em São Paulo e hoje estava participando com os demais colegas policiais, de uma operação na Vila dos Pescadores, tendo como alvo a repressão da TRÁFICO DE DROGA. Estava a pé, observando, quando percebeu à distância um indivíduo que, ao observar a aproximação policial, iniciou um procedimento de fuga, sendo acompanhado pelo depoente e outros policiais. O indivíduo adentrou em uma residência, sendo detido e, de imediato, foi dizendo que aquela seria a sua residência. Identificado como WESLLE CASTILHO DE BRITO SILVA, indagado por qual razão evadira-se, nada disse. Indagado se havia algo de de ilícito na residência, a princípio negou. Todavia, neste momento, adentrou a Sra. Crislaine, identificada com a esposa de WESLLEY. Com a permissão de CRISLAINE passaram a procurar algo ilícito, quando o próprio WESLLEY indicou uma sacola

colorida, afirmando que no seu interior havia material assemelhado a drogas conhecidas como maconha, cocaína. Da mesma forma, no banheiro, no interior de uma saboneteira havia quatro cartuchos de calibre 9 mm, intactos. Sobre uma mesa, localizaram-se duas folhas de papel, contendo anotações sobre o comércio ilícito de droga e um deschavador, mais o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), sendo que deschavador é um instrumento usado para triturar o entorpecente conhecido como maconha. Quando se dispunham a vir à distrital, surgiu um indivíduo, identificado como irmão de CRISLAINE, WAGNER FERREIRA DOS SANTOS, que passou a proferir injúrias contra os policiais presentes. Encaminhados todos à unidade distrital, apresentados ao Delegado de Polícia signatário, elaborando-se exames periciais e decorrendo em positividade para a entorpecência do material apresentado, cocaína e maconha, discriminados e pesados em autos próprios, deu-se a WESLLEY a voz de prisão pelas condutas apresentadas e a WAGER, elaborou-se o TERMO CIRCUNSTANCIADO por DESACATO" (fls. 16).

Em Juízo reiterou sua narrativa prestada em solo policial e confirmou a narrativa de seu colega de farda.

Em solo policial, o acusado WESLLEY CASTILHO DE BRITO SILVA disse que a droga não lhe pertence, e exerceu o direito de se manifestar apenas em Juízo (fls. 08/09). Interrogado em Juízo, disse que no dia dos fatos adentraram 3 policiais em sua residência. Chegaram já falando seu nome e que "a casa tinha caído", pois havia uma outra pessoa o havia denunciado. Pegaram seu celular e o amarraram em uma cadeira. Os policiais o espancaram e falaram que "o enterrariam dentro do maré" se não desse o paradeiro das drogas. Também algemaram sua esposa assim que ela adentrou na residência. Não havia drogas ou munição em sua residência. Essa diligência toda demorou em torno de 1 hora.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, não ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

No caso em tela, a despeito da confissão, o Réu deve ser absolvido em razão da ilicitude da prova, que por sua vez decorreu da ilegalidade na violação do seu domicílio.

Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Consabido que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148). Nesse mesmo diapasão, Guilherme de Souza Nucci esclarece que "suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473). Destarte "é necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal)" (STJ, RHC nº 158580/BA, Rel.

Min. Rogério Schietti Cruz, j em 19.04.2022) razão pela qual “não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial” (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Assim, a prova está maculada, conforme art. 157, do Código de Processo Penal: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

Ora, a casa é asilo inviolável, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso, não havia motivo justificado para que a polícia adentrasse à residência do réu. A suposta crença de que no local havia produto de crime – mesmo sendo o suposto crime permanente – não autorizava que sem autorização de morador ou ordem judicial adentrassem no local, sobretudo pela inexistência de risco de perecimento do suposto produto criminoso.

Para se legitimar o ingresso em domicílio alheio, é necessário que tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.

Na hipótese vertente, “o ingresso forçado na casa onde estava o Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado em informação de inteligência policial (notícia anônima) como único elemento prévio à violação do domicílio” (STJ, STJ - HC 496.420/SP, j. 30/05/2019, relatora Ministra Laurita Vaz). Por certo, “embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida”, a “proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois” (STF, RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016)

E nem se diga que, por se tratar o tráfico e a posse de drogas de crimes permanentes, havia situação de flagrante delito que justificava o ingresso. O fato de ter supostamente havido denúncias anônimas de traficância não altera a situação, pois, naquele caso, não havia nenhum elemento concreto que indicasse a prática de tráfico. Nunca é muito gizar que “[...] denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição a direitos individuais” (STJ: RHC n. 53134/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 26/05/2015).

Os policiais sequer mencionam atos de traficância concreta do réu na ocasião, limitando-se a dizer que resolveram ir até a residência para apurar as denúncias recebidas via disque denúncia. Trago à baila, nesse sentido, recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão preventiva a relevante quantidade entorpecentes apreendidos em poder da paciente, tratando-se de 132 pedras de crack, 84 papélotes de cocaína e ainda 26 trouxinhas de maconha, não foi apontado nenhum elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência da paciente, citando-se apenas a verificação de denúncias de tráfico de drogas que receberam através do “Disque Denúncia”, e a fuga do adolescente.

2. Verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio,

determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, quando não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância no domicílio violado.

3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura da recorrente, TEREZA RODRIGUES, e de ofício determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001783-23.2016.8.26.0695.(STJ, Sexta Turma, RHC 83.501/SP, Rel. Mini. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018)

Para obviar esse tipo de situação, que instabiliza e põe sob permanente risco referida franquia constitucional, não seria desarrazoado sustentar que a hipótese de flagrante delito a que alude o art. 5º, XI, da Constituição da República deveria ao menos em interpretação restritiva compatível para norma que, a rigor, excepciona importantíssima liberdade pública, denotar a situação em que um crime esteja ocorrendo no interior da residência e a urgência não permite aguardar a providência mais segura, cautelosa, a prévia autorização judicial.

Em nenhum momento, foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos, tampouco foi feita menção a eventual movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas.

Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.

Há apenas a descrição de que, quando o recorrido avistou os policiais, empreendeu fuga. Uma vez que não há nem sequer como inferir, de fatores outros que não a mera fuga ante a iminente abordagem policial, que o recorrido estivesse praticando delitos de tráfico de drogas ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, no domicílio do acusado, de drogas, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância.

No caso, "houve mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo ora recorrido, o que não configurou, por si só, 'fundadas razões' a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial" (STJ - REsp: 1690854 RJ 2017/0208328-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).

Não se ignora aqui a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806)). Tal tese, todavia, deve ser adequadamente analisada e interpretada em cada caso concreto a fim de evitar se converter em salvo conduto para que a polícia ingresse em qualquer residência à procura de drogas. É preciso fazer, assim, a devida filtragem constitucional da expressão "fundadas razões", como vem fazendo o Superior Tribunal de Justiça nos julgados acima citados. O voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz no RHC 83501/SP bem esclarece a situação:

"Não se desconhece que, consoante afirmou o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do referido RE n. 603.616/RO, "A busca e apreensão domiciliar é uma medida invasiva, mas de grande valia para a repressão à prática de crimes e para a investigação criminal" (p. 10 do acórdão). Também não perco de vista que, não raro, é tênue a distinção dos limites circunstanciais entre a legitimidade da ação de ingresso e a afetação do direito à inviolabilidade de domicílio.

No entanto, é de particular importância (re)pensar em que medida o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa uma intervenção restritiva legítima do ponto de vista constitucional, e não uma violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Isso porque

a ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. Sobre esse cuidado de ocorrerem abusos na invasão de domicílio, Arion Escorsin de Godoy e Domingos Barroso da Costa advertem que: Sabe-se que o flagrante autoriza a violação de domicílio, mas essa relativização do direito fundamental previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição não significa abertura a ações policiais que mais se assemelham a apostas lotéricas, em que o prêmio – dependente da sorte do jogador – é o encontro de indícios da prática de tráfico de drogas e a consequente prisão de quem possa ser seu autor. Desconstruindo a afirmativa que deve ser analisada frente às narrativas comuns aos autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, descobre-se que, em regra, não há uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicílio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental. Porém, como em um passe de mágica juridicamente insustentável, por uma convalidação judicial, a apreensão de objetos ou substâncias que sejam proibidos ou indicativos da prática de crime e a prisão daquele(s) a quem pertença(m) travestem de legalidade uma ação essencialmente – e originariamente – violadora de direito fundamental. E a realidade pode ser ainda mais perversa, na medida em que se sabe que abusos policiais não são tão incomuns quanto se deseja, não sendo raros os casos de manipulação das circunstâncias, como se dá nos chamados flagrantes forjados. (O consentimento e a situação de flagrante delito nas buscas domiciliares).

Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um "terceiro neutro e desinteressado") só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente."

Veja-se que nos acórdãos citados além das denúncias anônimas houve a fuga do acusado e até o "consentimento" do morador, mas mesmo assim se entendeu ilícita a prova obtida, em virtude da fragilidade dos elementos.

É bastante comum nas narrativas dos processos criminais a alegação de que "o réu franqueou a entrada dos policiais na residência", quando então os objetos ilícitos foram encontrados. Ora, quem em sã consciência, sabendo que possui objetos ilícitos dentro de sua residência, consente livremente com o ingresso daqueles que irão justamente buscar tais objetos e prender o morador em flagrante delito? É no mínimo difícil de imaginar que essas supostas autorizações efetivamente aconteçam na prática e, caso aconteçam, que sejam externadas livremente, e não pela pressão e temor em relação aos policiais.

Vale aqui transcrever a bastante didática lição do Superior Tribunal de Justiça no mesmo acórdão acima citado sobre a autorização de ingresso no domicílio (RESP Nº 1.690.854 - RJ (2017/0208328-0), de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, de 04.05.2017):

"Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar".

Em relação ao cenário brasileiro, Cleunice Pitombo, na mesma linha, destaca: "Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarcta o passo" (Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 133-134)."

E o fato de o portão encontrar-se aberto também não basta para o ingresso na residência, pois não retira a inviolabilidade do domicílio. Vejamos trecho

elucidativo do voto do Ministro Nefi Cordeiro no recente julgamento do RHC 83.501/SP:

“Verifica-se, então, pelos depoimentos dos policiais, ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, pois, como destacado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no voto-vista, não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância naquele local, e acrescenta-se que o fato do portão da residência encontrar-se aberto não justifica a entrada dos policiais sem autorização judicial.”

Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese eventual boa-fé da polícia, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial, valendo destacar, ademais, que sequer havia urgência que impossibilitasse a solicitação de prévia autorização judicial.

Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – art. 157, §1º, CPP), o que impõe a sua absolvição, por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER WESLLEY CASTILHO DE BRITO SILVA, qualificado em fls. 08, da imputação da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Fica revogada a prisão preventiva decretada (fls. 42-46).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido em decorrência de Tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito” (tema 647).

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA